

1500207-42.2021.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHAIANE MARIA BUBLITZ KORTE

Comarca: Bariri

Foro: Foro de Bariri

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... de Drogas, com a majorante pertinente ao tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal (art. 40, V, da Lei de Drogas), tal como novamente aqui ocorreu.

E mais, as conversas contidas em seu celular demonstram, à saciedade, sua dedicação às atividades criminosas, fazendo do delito de tráfico seu meio de vida, com constantes deslocamentos até a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bariri

Foro de Bariri

1ª Vara

Av. Claudionor Barbieri, nº 488, Bariri-SP - cep 17250-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500207-42.2021.8.26.0598 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500207-42.2021.8.26.0598

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2150717/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAU, 18299305 - CENTRAL POL.JUD-JAU, 2933/21/406 -

CENTRAL POL.JUD-JAU, 2150717 - DEL.POL.ITAJU, 2933/21/406 - DEL.POL.ITAJU

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

ROSINALDO FERREIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHAIANE MARIA BUBLITZ

I. RELATÓRIO

ROSINALDO FERREIRA e LUÍS CARLOS RIBEIRO SANTA ROSA ou LUÍS CARLOS RIBEIRO QUIROGA, ambos qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público, o primeiro, como incurso no artigo 33, caput, c.c art. 40, V, ambos da lei 11.343/2006; e o segundo, como incurso no artigo 33, caput, c.c art. 40, V, ambos da lei 11.343/2006, c.c artigo 29 do Código Penal. Constou na inicial acusatória que o primeiro denunciado, em concurso de agentes com segundo, entre estados da Federação, transportou, sem autorização e para fins de tráfico, 05 (cinco) porções de cocaína na forma de crack, acondicionadas em garrafas pets transparentes com peso bruto de 5.230 g (cinco quilos e duzentas e trinta gramas). Constou ainda que,

nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, o segundo denunciado, também entre estados da Federação, concorreu de qualquer modo para o crime de tráfico acima narrado, mediante auxílio material.

Anteriormente, houve prisão em flagrante de Rosinaldo, convertida em prisão preventiva (fls. 123/124).

Decretada a prisão preventiva do denunciado Luís Carlos, às fls. 261/266.

Defesa prévia de Rosinaldo Ferreira às fls. 347/348; e de Luís Carlos, às fls. 361/367.

Às fls. 379/381, foi recebida a denúncia.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas três testemunhas e interrogados os réus.

O Ministério Público, às fls. 591/608, requereu a procedência dos pedidos condenatórios. Afirmou que a materialidade e a autoria de ambos os réus ficaram demonstradas, tecendo considerações sobre a dosimetria de pena e regime inicial a ser fixado.

A Defesa de Luís Carlos, às fls. 619/636, em alegações finais, apregoeou a ausência de prova suficiente da autoria. Alegou a aplicabilidade da teoria da perda da chance probatória. Sustentou inexistirem provas para a condenação. Requereu, ao final, a absolvição; subsidiariamente, a aplicação do art. 33, §4, da LD; e o direito de recorrer em liberdade.

A Defesa de Rosinaldo Ferreira, às fls. 637/640, requereu o afastamento da agravante da reincidência, ante o decurso do período depurador; e a aplicação do art. 33, §4º, da LD.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O feito se encontra formalmente em ordem, de modo que, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal, não havendo, ainda, nulidade a sanar, passo ao exame do mérito.

A existência do fato (materialidade) está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 17/20, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 23/25 e pelos laudos de fls. 27/28 e fls. 177/180, relatório policial de fls. 535/538, laudo pericial de fls. 547; e, ainda, pela prova oral coligida em Juízo.

Passo ao exame da autoria.

A testemunha Fagner Duque, policial militar rodoviário, declarou que estavam de serviço no dia. Realizavam patrulhamento, quando passou um Ford Focus, cor cinza, que chamou a atenção. Consultaram e verificaram que era de Serrana/SP. Ao realizarem a abordagem, Luís Carlos aparentou bastante nervosismo. Fizeram perguntas em separado, com a passageira. A passageira alegava que estava em viagem de um dia, a Três Lagos. Luís Carlos dizia que há três dias estaria em Campo Grande, e que teria ido levar uma tia. A moça disse que estaria indo para Matão, e ele, para Jaú. Então, passou uma Parati vermelha, e notaram que a placa era de Matão. Fizeram uma vistoria prévia, e verificaram que não havia nada solto no veículo. Desconfiaram que poderiam estar atuando como batedores de uma carga ilícita, para avisarem caso houvesse polícia. Pegaram a documentação de Luís Carlos, que, na ocasião, entregou uma CNH de "Luís Carlos Ribeiro Santa Rosa" e os telefones deles, e solicitaram que seguissem até o posto mais próximo, para que aguardassem os policiais – pois, caso contrário, não conseguiriam chegar ao veículo Parati. Feito isso, saíram e conseguiram realizar a abordagem. Abordaram Rosinaldo com a Parati. Rosinaldo dizia que estava vindo de Campo Grande, estava nervoso e dizia que teria ido levar uma tia, o que causou estranheza. Fizeram uma vistoria e chegaram ao tanque de combustível. Ao desmontarem a boia do tanque, verificaram garrafas PET com produto dentro. Retiraram cinco garrafas PET com "crack".

Rosinaldo confessou que estava transportando a droga e a levaria até Jaú. Luís Carlos se evadiu. Foram até a Delegacia de Jaú e, lá, passaram a documentação, a CNH de Luís Carlos "não dava consulta" (sic). Contudo, ao verificarem os números,

constava um nome diferente, e histórico de condenação por tráfico. Em diligências, verificaram que se tratava da mesma pessoa. “Nisso daí, na presença do Delegado... A última ligação que tinha no telefone... Foi discado”. Um aparelho celular tocou, dos três telefones que tinham sido deixados abandonados por Luís Carlos e pela passageira. Atuam na área da Companhia. Existem pedágios na região. A passageira não foi qualificada. Quando passou a Parati, tinham recolhido os documentos de Luís, a passageira não tinha documentos. Quando Luís Carlos foi preso, ele estava preso com uma mulher, mas não era a mesma.

A testemunha Juliano Soares Silva, policial militar, prestou declarações em idêntico sentido à testemunha Fagner. Perguntado sobre o porquê de a passageira não ter sido identificada, respondeu que, durante a abordagem, foram recolhidos os documentos de Luís, e, nisso, passou o veículo Parati e já foram atrás, para que não se evadisse.

A testemunha Marcílio César F de Mello, delegado de polícia, declarou que a CPJ efetuou uma prisão em flagrante. O inquérito foi remetido a Itaju. No veículo de um dos réus, uma Parati, havia entorpecentes. Quanto ao outro réu, foi abordado, juntamente com uma passageira, e foi abordado em primeiro lugar. O réu do veículo Parati dizia que estaria vindo de Campo Grande, mas prestava uma versão confusa. Ao que se recorda, houve uma ligação do condutor da Parati e a chamada foi completada em um dos três telefones retidos da primeira abordagem, situação que permitiu verificar a relação entre ambos os réus.

O réu Luís Carlos Ribeiro Quiroga (o qual declarou que seu nome de solteiro é Luís Carlos Ribeiro Santa Rosa), em seu interrogatório judicial, declarou que trabalha como Uber. Não conhece Rosinaldo. Tinha um GPS em seu veículo. Não estava trabalhando pelo aplicativo do Uber quando foi abordado; há um grupo de pessoas que pedem corrida, de forma particular. Naquela noite, haviam lhe pedido uma corrida particular, de umas “meninas”, para que as levassem a Pongai. Havia feito essa corrida, para Pongai, de manhã. Na volta, trouxe essa menina, que tinha tatuagens. Estava voltando para Matão. Quando foi abordado, disse aos policiais que vinha de Pongai, em momento nenhum disse que vinha de Campo Grande. Entregou a habilitação. O policial lhe pediu que fosse até o Posto de Combustível. Seu celular era Samsung, talvez cinza, não lembra a cor. Na CNH apreendida, constava seu nome de solteiro (Luís Carlos Ribeiro Santa Rosa) e que estava vencida. Foi encontrar os policiais no posto e lá permaneceu por 10 ou 15 minutos, sem retorno dos policiais. Disse acreditar que a retenção da CNH teria sido pelo fato de estar vencida. Não permaneceu no posto, porque a cliente estava exigindo que a levasse, e chegou a procurar outro Uber. Deixou a passageira em Matão. São comuns as corridas noturnas com mulheres “de programas” entre casas noturnas de Matão e Pongai. Além do trabalho de Uber, mantinha com sua filha uma pizzeria e uma lanchonete, ambas no mesmo espaço, mas que seu trabalho era restrito ao fechamento do caixa no domingo e a compra de material.

O réu Rosinaldo Ferreira, em seu interrogatório judicial, declarou que de segunda a quinta-feira teria ido até Guaraçaí e Jales, para arrecadar frutas que comercializa. Visitou fazendas. Quando foi parado por policiais, pensou que seria pelo fato de que tem alguns débitos referentes à compra de sua Parati. Manteve-se calmo e agia “naturalmente” durante todo o tempo. Os policiais, ao descobrirem que ele estava sendo investigado por estupro, mediante uma notificação que havia em seu porta-luva, disseram que “um Jack deveria estar morto” e iriam “arrumar um B.O. pra você já” para ele, chegando em “tom agressivo”. Os policiais o ameaçaram de morte, o algemaram e o levaram para uma estrada vazia, perguntando se “queria morrer ou ir para a cadeia”. Colocaram arma em sua cabeça. Não lembra o que falava. Orava a Deus, pois é evangélico. Vê na televisão situações em que os policiais fazem injustiça com os outros, nunca achava que aconteceria consigo também. Não lembra o que fez, apenas que rezou. Nessa hora, chegaram mais 4 (quatro) policiais sem fardas, e o Sargento começou a falar para eles que iriam pegar as garrafas com drogas que teriam apreendido em outra ocorrência e incriminar ele e o outro carro, pois ambos já teriam “passagem”. Um dos policiais foi buscar as garrafas com as drogas, colocou-as em seu colo e começaram a tirar fotos dizendo “essa vai para o Instagram”. Seu celular não foi apresentado para a polícia, que o modelo dela seria

A01 e que possui as notas fiscais. Recebeu chutes. Não fez exame de corpo de delito. Foi levado para a Delegacia de Polícia e ameaçado caso contasse algo. Não contou sobre as agressões sofridas para o Delegado de Polícia pois teve medo. Na Delegacia, prestou sozinho seu depoimento. Jamais assumiu que estava transportando drogas, nem mesmo quando estava sendo torturado ou ameaçado. A droga foi "plantada" pela polícia. Mesmo que ele quisesse ser traficante, após entrar na igreja ele não mais poderia. Jamais contou para ninguém sobre as agressões que teria sofrido na Delegacia.

Em que pesem as teses defensivas, a análise do conjunto probatório revela a existência de prova firme, segura e suficiente no tocante à demonstração da autoria de Rosinaldo e participação de Luís Carlos, revelando-se absolutamente desprovida de suporte fático a versão de autodefesa de ambos os réus.

De fato, a prova testemunhal foi uníssona ao revelar a dinâmica dos fatos.

Nesse caminho, consoante depoimento das testemunhas Fagner, Juliano e Marcílio, policiais militares, durante o patrulhamento da rodovia, efetuaram a abordagem do veículo que Luís Carlos conduzia, tendo tal réu, então, apresentado respostas confusas aos questionamentos efetuados pelos policiais militares.

Não bastasse isso, chama a atenção o fato de que havia três celulares para apenas dois ocupantes do veículo, circunstâncias externas e objetivas que provocaram fundada suspeita de atuação ilícita por Luís Carlos, na condição de "batedor".

Ato contínuo, um veículo "Parati", com placas de Matão/SP, dirigido por Rosinaldo, passou pela Rodovia, e, efetuada a abordagem, Rosinaldo apresentou a mesma versão de Luís Carlos (teria conduzido uma "tia" a Campo Grande), e, dada a estranheza da situação, em busca veicular, foram então encontrados os entorpecentes que tal réu transportava.

Quanto a Luís Carlos, restou infrutífera sua prisão em flagrante, pois já evadido.

Note-se que, conforme declararam as testemunhas, ao discarem o último número registrado no telefone apreendido com Rosinaldo, pôde-se verificar que um dos telefones que estavam no interior do veículo de Luís Carlos tocou, confirmando o liame subjetivo entre ambos, mediante o exercício da função de "batedor" por Luís Carlos, em benefício de Rosinaldo.

A versão fática apresentada pela prova testemunhal é confirmada pela prova documental, uma vez que, conforme informações prestadas pela Operadora Tim, à fl. 578, de fato, no dia 03/06/2021, o telefone com IMEI 354980111240938 recebeu ligação do telefone 5511951289272. Evidente, assim, que ambos se comunicavam no dia dos fatos, a fim de possibilitar a atuação criminosa.

E mais, o relatório policial de fls. 535/538, calcado no laudo pericial de fls. 547, comprovou que LUÍS CARLOS constantemente se deslocava até a divisa entre Brasil e Bolívia, com intuito de adquirir drogas destinada ao tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido, observe-se o seguinte diálogo, de fl. 541:

- PTT-20210502-WA0056.opus_Converted

"Deixa eu falar um negocio pro cê... Cê não qué que eu leve alguma coisa pra você daqui cara? Tendeu? Se você quisé, cê me manda o dinheiro, esse aí que você tem na mão e aumenta uns 5 mil reais e eu levo um barato.. um daqui pra você mano, pro cê levanta um dinheiro. Se você quisé, se você não quisé do mesmo jeito eu chego aí ... te do um barato ali no preço dali e você me passa o dinheiro que tem que me passa, você que sabe. É que eu tô aqui na fronteira, na casa da minha mãe, vou descer lá pra Bolívia agora, comprar o que eu tenho que compra e lá pra terça ou quarta-feira já to subindo aí"

- PTT-20210510-WA0026.opus_Converted

"Não parceiro, faz isso não, deposita o dinheiro pra mim, eu to aqui na fronteira carai.... oooh você vai deixar lá? Se é loco?! Deposita aí pra mim, é só ir ali na caixa, é só i ali na... na lotérica aí"

- PTT-20210510-WA0055.opus_Converted

"Mano, to aqui na fronteira, aqui na fronteira com a Bolívia e o Brasil mano, o mais dinheiro que você puder mandar pra mim é melhor..."

Tais comunicações robustecem, assim, a versão acusatória, comprovada pelas provas orais, de que Luís Carlos e Rosinaldo estavam envolvidos na empreitada criminosas, com o primeiro atuando como “batedor” para Rosinaldo – o qual, a seu turno, efetuava o transporte das drogas apreendidas no veículo Parati.

Observo, ainda, que o réu Rosinaldo mentiu deliberadamente em Juízo, pretendendo atribuir aos policiais militares condutas criminosas, no intuito de se eximir de sua responsabilidade penal.

Note-se que, em juízo, Rosinaldo alegou que foi agredido por policiais militares e não foi submetido a exame de corpo de delito.

Entretanto, ao contrário do que declarou, o réu foi, sim, submetido a tal exame, como se vê às fls. 121/122, tendo o profissional médico atestado a inexistência de lesões.

Não há indício algum de que policiais militares tenham praticado as condutas criminosas que o réu lhes imputa, consistentes em agredi-lo e imputar-lhe a propriedade de drogas que os próprios agentes de segurança pública teriam ali posto, versão fantasiosa e sem lastro no conjunto de prova.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas assim como as demais, não tendo sido apresentada nenhuma razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o TJSP: “Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

Dessa forma, considerando que não há nos autos elementos que coloquem em dúvida as palavras dos policiais quanto à conduta dos réus, não é lícito presumir que queiram prejudicar os acusados, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Induvidosa, portanto, a atuação delitiva dos réus, com consciência e vontade, não encontrando amparo a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória.

Não há falar em perda da chance probatória, por não terem os policiais identificado a passageira que fazia companhia a Luís Carlos.

No caso dos autos, a identificação só não foi possível, como declararam os policiais militares, porque o próprio acusado se evadiu, não comparecendo ao Posto de Combustível indicado pelos agentes de segurança – que, em número escasso, não teriam condições materiais de abordar ambos os veículos ao mesmo tempo.

Se o acusado, deliberadamente, decidiu por descumprir a ordem policial e se evadir, não lhe cabe, agora, alegar ilegalidade alguma, pois sua conduta foi decisiva para a impossibilidade de obtenção dessa prova. Como se sabe, no Direito, a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza. Não sem razão o art. 565 do CPP preceitua: “Art. 565. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.”.

Afasto, assim, tal tese defensiva do réu Luís Carlos.

Noutro giro, o exame aprofundado do conjunto de prova revela o acerto da tipificação contida na denúncia.

Isso porque, Rosinaldo, que transportava os entorpecentes, praticou o núcleo do tipo descrito no art. 33 da LD, e, portanto, à luz da Teoria Objetivo-Formal, adotada pelo art. 29, caput, do CP, foi o autor do crime.

Já Luís Carlos, ao atuar como “batedor”, concorreu para o crime, sem executar a conduta criminosas. Foi, portanto, partícipe do crime de tráfico, na modalidade de participação material, já que prestou auxílio material para a prática do ato executório. Saliento que sua participação, como “batedor” era significativamente relevante para o êxito da ação criminosas, descabendo cogitar de participação de menor importância.

Nessa quadra, impositiva a responsabilização do réu Luís Carlos, à luz da Teoria da Acessoriedade Limitada, já que o fato praticado por Rosinaldo era típico e ilícito. Ademais, o tráfico de drogas, nas modalidades “trazer consigo”, “manter em

depósito", "guardar" e "transportar", prescinde da prova da mercancia (Jurisprudência em teses, STJ - Edição 131), bastando a demonstração de tal finalidade, cabalmente comprovada nos autos pelos depoimentos já mencionados, assim como, repiso, pela quantidade e forma de acondicionamento das substâncias, de naturezas distintas, tudo de modo a facilitar a entrega a terceiros. Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PRINCÍPIO DA DIVISIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIAS SEPARADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que "para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014)." (STJ. HC 496.536/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

Ainda, conforme preceitua o art. 28, §2º, da Lei de Drogas, para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, há de se atentar à: a) natureza e quantidade da substância apreendida; b) ao local e às condições em que se desenvolveu a ação; c) às circunstâncias sociais e pessoais; bem como e) à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso em concreto, descabido cogitar de destinação das drogas a consumo pessoal, seja pela grande quantidade (5 porções de cocaína na forma de crack, acondicionadas em garrafas pets transparentes com peso bruto de 5.230 g), seja pelo local e condições em que se desenvolveu em ação - em Rodovia, com um dos réus atuando como "batedor" para outro, com ambos se deslocando entre estados da federação.

No tocante à tipicidade, impositiva a aplicação da majorante prevista no 40, V, da Lei nº 11.343/2006. Inegável o caráter interestadual do tráfico, já que Rosinaldo transportava os entorpecentes desde Campo Grande/MS, com o auxílio do réu Luís Carlos. Relembre-se que ambos admitiram, aos policiais militares, que provinham de Campo Grande/MS.

E mais, as conversas presentes no celular de Luís Carlos bem evidenciam que, constantemente, deslocava-se até a divisa entre Brasil e Bolívia em prol da prática do delito de tráfico, tudo a evidenciar que o transporte interestadual era mesmo o modus operandi dos acusados. Assim, cabe lembrar, no aspecto, a Súmula 587 do STJ, que preceitua: "Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da lei 11.343/06 é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual."

De rigor a aplicação, portanto, da referida causa de aumento, para ambos os réus. De outro lado, quanto ao privilégio previsto no art. 33, §4º, do Código Penal, o dispositivo prevê: "§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços (...), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa."

Impende asseverar que, na linha do entendimento do STF, a quantidade de droga, isoladamente, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 (RHC 138715/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 23.05.2017, Informativo 866).

No mesmo sentido tem o Superior Tribunal de Justiça se manifestado, conforme HC 726.726/MG (relator Min. João Otávio de Noronha). No REsp n. 1.887.511/SP, aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado relatado pelo Min. João Otávio de Noronha, especificamente com relação à natureza e quantidade das drogas apreendidas, definiu as seguintes balizas:

- a) Devem ser valoradas na primeira etapa da dosimetria da pena, pela necessidade de observância dos vetores indicados no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 como preponderantes;
- b) Não podem ser utilizadas concomitantemente na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena; e
- c) Supletivamente, podem ser utilizadas na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

No caso dos autos, e observados rigorosamente os critérios legais e jurisprudenciais, tem-se que não cabe a aplicação da causa de diminuição para nenhum dos réus.

A certidão de antecedentes de Rosinaldo, às fls. 83/87, comprova que é reincidente específico, ante a condenação no processo de nº 0004529-32.2007.8.26.0062 pelo delito do art. 33, caput, da LD.

Esclareço que a pena foi extinta em 21/10/2016, conforme se vê à fl. 86 (no processo de execução de pena - VEC Nº 694.142, o réu Rosinaldo Ferreira, foi condenado por sentença judicial transitada em Julgado em, 23/09/2009. Em 12/09/2016, foi declarada extinta a pena privativa de liberdade pelo integral cumprimento).

Logo, ainda não havia decorrido o período depurador (art. 64, I, do CP) à data do fato deste processo, ocorrido em 03/06/2021.

Outrossim, o réu Luís Carlos é reincidente, diante de condenação já transitada em julgado no processo de nº 0002625-65.2019.8.26.0026 (fls. 258/259), em que sentenciado pela prática de delito da Lei de Drogas, com a majorante pertinente ao tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal (art. 40, V, da Lei de Drogas), tal como novamente aqui ocorreu.

E mais, as conversas contidas em seu celular demonstram, à saciedade, sua dedicação às atividades criminosas, fazendo do delito de tráfico seu meio de vida, com constantes deslocamentos até a fronteira entre Brasil e Bolívia em prol da mercancia espúria.

Assim, inaplicável a benesse prevista no art. 33, §4º, da LD.

Portanto, suficientemente comprovadas a existência e a autoria e participação pelos réus, e não se verificando a ocorrência de causa ou circunstância que exclua o crime ou os isentem de pena, é impositiva a responsabilização penal.

Passo, então, à dosimetria da pena, com atenção às funções preventiva e repressiva da sanção penal e observância do princípio da individualização da pena, nos termos do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, art. 42 da Lei 11.343 e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal.

Dosimetria e individualização da pena

Na primeira fase, convém rememorar o art. 42 da Lei de Drogas, segundo o qual “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”.

Em atenção às circunstâncias do caso em tela, impositivo o aumento da pena-base, para ambos, em razão da grande quantidade de entorpecentes (cinco quilos e duzentas e trinta gramas – auto de exibição e apreensão de fls. 23/24), e, ainda, da natureza do entorpecente (cocaína em forma de “crack”), com notório e expressivo potencial lesivo.

Esclareço que, alinhando-me com a jurisprudência do STJ, revejo entendimento anterior para considerar que a quantidade e a natureza da droga constituem um único vetor na pena-base. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: “a quantidade e natureza da droga, em conformidade com a interpretação do art. 42 da Lei 11.343/2006 somente pode ser valorada como uma única vetorial, não como fizeram as

instâncias ordinárias, separando-se a natureza e a quantidade como se fossem duas circunstâncias judiciais distintas" (STJ, HC nº 567.261 - RJ- Rel. Min. Nefi Cordeiro).

Registro que a natureza da droga será considerada apenas neste momento da dosimetria, em conformidade com o entendimento 6ª Turma do STJ, in verbis: "(...) a valoração da quantidade e/ou da natureza da droga é restrita a apenas uma das fases da dosimetria, sendo vedada a sua consideração concomitante na primeira fase para aumentar a pena-base e na terceira fase para afastar ou mesmo modular o quantum de redução" (STJ. AgRg no HC 605.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).

Sobre a conduta social e a personalidade dos acusados não foram amealhados elementos suficientes nos autos.

Conforme certidão de fls. 83/87, o réu Rosinaldo possui mau antecedente, ante a condenação no processo de nº 0000145-60.2006.8.26.0062 (não se aplicando, ao mau antecedente, o período depurador, conforme pacífica jurisprudência do STJ).

Luís Carlos não ostenta mau antecedente (a condenação no feito 0002625-65.2019.8.26.0026 será considerada na segunda fase).

Os motivos que os levaram a cometer o delito são normais à espécie.

As consequências foram normais.

A culpabilidade de ambos, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta, deve ser considerada normal.

Não há falar em comportamento da vítima em tal espécie de delito (crime vago).

Logo, de rigor o aumento da pena-base, de modo que, considerando duas circunstâncias judiciais negativas (natureza e quantidade dos entorpecentes; antecedentes) para Rosinaldo; e uma para Luís Carlos (natureza e quantidade dos entorpecentes); fixo-lhes as seguintes penas-base:

- a) Para Rosinaldo, em 06 anos e 08 meses de reclusão, mais pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre a capacidade econômica do réu;
- b) Para Luís Carlos, em 5 anos e 10 meses de reclusão, mais pagamento de 583 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre a capacidade econômica do réu;

Na segunda fase do cálculo, não incidem atenuantes para nenhum dos réus.

Ambos, porém, são reincidentes, nos termos do art. 61, I, do CP (Rosinaldo, ante a condenação no processo de nº 0004529-32.2007.8.26.0062 pelo delito do art. 33, caput, da LD, não atingida pelo período depurador; Luís Carlos, ante a condenação no processo de nº 0002625-65.2019.8.26.0026, conforme fls. 258/259).

Logo, agravo a pena de cada um em 1/6, para fixá-la, na etapa intermediária:

- a) Para Rosinaldo, em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 777 dias-multa, no valor unitário mínimo legal;
- b) Para Luís Carlos, 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, está presente a causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/2006), e não incidem causas de diminuição.

Assim, agravo a pena de cada réu em 1/6, para fixá-la, na etapa final:

- a) Para Rosinaldo, 9 anos e 26 dias de reclusão, e 906 dias-multa, no valor unitário mínimo legal;
- b) Para Luís Carlos, 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, e 793 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Regime inicial

Diante do quantum das penas impostas e da reincidência, fixo aos réus o regime inicial FECHADO.

Art. 387, §2º, do Código de Processo Penal

Não há falar em aplicação da regra prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal (detração penal). O benefício não se confunde com progressão de

regime; e, ainda, a matéria deve ser analisada pelo Juízo da Execução (STJ, HC 443.498/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe15/06/2018).

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e suspensão condicional da pena

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois não preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP.

Ainda, é também incabível a suspensão condicional da pena, diante do não preenchimento dos requisitos do art. 77 do CP.

Indenização mínima

Em função de o delito praticado ser classificado como crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação de valor para a reparação civil de ofendido (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

III. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, conforme art. 387 do CPP, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

a) CONDENAR o réu ROSINALDO FERREIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, c.c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e 906 dias-multa, no valor unitário mínimo legal;

b) CONDENAR o réu LUÍS CARLOS RIBEIRO SANTA ROSA ou LUÍS CARLOS RIBEIRO QUIROGA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c art. 40, V, ambos da lei 11.343/2006, c.c artigo 29 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e 793 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

“Status Libertatis”: pelos mesmos motivos já elencados anteriormente nos autos, e não havendo fato novo que altere a situação da custódia, estando presentes os fundamentos e os requisitos da prisão preventiva (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal), não poderão os réus recorrerem em liberdade. Mostra-se, pois, imperiosa a manutenção dos sentenciados no cárcere, não só para assegurar a aplicação da lei penal, como também para garantia da ordem pública.

Logo, nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade. Expeça-se o necessário. Caso não realizada até a presente data, autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos, nos termos dos artigos 50, §3º e 50-A da Lei Antidrogas, reservando-se amostra para eventual contraprova. Após o trânsito em julgado, fica autorizada a destruição das amostras guardadas para contraprova, nos termos do art. 525, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Expeça-se a guia de execução provisória. Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe.

Transitada em julgado:

a) intímem-se os réus para pagamento da multa;

b) oficie-se ao IIRGD;

c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos dos apenados, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Decreto o perdimento do valor apreendido e objetos apreendidos em favor da União. Com o trânsito em julgado, oficie-se (Lei 11.343/06, artigo 63, § 1º), exceto o veículo apreendido, cuja restituição à terceira de boa-fé, Vanessa Miranda Caires, autorizo, à luz dos esclarecimentos de fl. 613 e manifestação ministerial de fl. 618.

Expeçam-se as certidões aos Defensores Dativos, conforme Termos/Valores do Convênio OAB/Defensoria.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

Bariri, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA